

1519770-65.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... do Código Penal não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º) STJ. 3ª Seção. REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 25/05/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1087) (Info 738)".

No mais, presente no caso a tentativa, já que o delito de furto não se consumou pois o réu foi surpreendido pelos policiais no momento em que tentava se evadir do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1519770-65.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1519770-65.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON CABRAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

CLEITON CABRAL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso II c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, segundo apurado, no dia 15 de agosto de 2021, por volta das 23h00min, em período de repouso noturno e de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), na Rua Duarte de Azevedo, 492 - Santana, nesta cidade e comarca, subtraiu para si, mediante escalada, aproximadamente 30 metros de fios elétricos, avaliados em R\$ 200,00, pertencentes à empresa vítima SPP BURGUER HAMBURGUERIA E LANCHONETE LT, representada por P.H.P.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado, notificado e apresentou resposta à acusação.

O laudo pericial do local dos fatos foi juntado a fls. 98/102.

Mantido o recebimento da denúncia, e não sendo o caso de acordo de não persecução penal ou de suspensão condicional do processo, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidos o representante da empresa-vítima, duas testemunhas policiais e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal.

Por sua vez, a Defesa pugnou pela improcedência da ação penal, requerendo a absolvição do réu com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal; o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno; bem como a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

O próprio réu ao ser ouvido em juízo, confessou a prática dos fatos narrados na denúncia. Disse que na data dos fatos entrou, junto com outras pessoas, em uma casa abandonada pela porta da frente, que estava aberta. As demais pessoas saíram do local e ele ficou. Encontrou uma escada dentro da casa abandonada e a usou para escalar até o estabelecimento comercial vizinho, onde subtraiu os fios. Em sequência, pulou o muro da casa vizinha para fugir, mas foi pego pelos policiais. A confissão do réu, ao contrário do alegado pela combativa Defesa, veio devidamente corroborada pelas outras declarações colhidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, o representante da empresa vítima, ao ser ouvido em juízo, declarou que os fios foram furtados da parte de cima do imóvel em que funcionava seu estabelecimento comercial. Percebeu a ação quando a luz de sua hamburgueria apagou repentinamente. Informou que gastou aproximadamente R\$ 400,00 e que os fios subtraídos pertenciam à fiação elétrica da casa onde funcionava sua hamburgueria. No mais, declarou que acionaram a polícia, que procurou o agente na parte inferior do imóvel, mas não o localizou. Contudo, quando os policiais estavam indo embora, a vizinha indicou a presença do réu no quintal de seu imóvel, onde ele foi preso em flagrante sob posse dos fios.

No mesmo sentido, os policiais ouvidos em audiência narraram que foram acionados pelo proprietário da hamburgueria, que indicou a presença de um indivíduo na parte superior de seu estabelecimento comercial. O réu foi localizado na casa ao lado sob posse de uma mochila que continha os fios subtraídos e um alicate. Ambos policiais indicaram acreditar que o réu tenha escalado o imóvel para ter acesso aos fios, visto que se tratava de um prédio alto, com dois andares e os fios foram subtraídos da parte superior do imóvel.

Ora, diante das provas colhidas nos autos, notadamente em razão da confissão do réu corroborada pelas versões uníssonas apresentadas pelo representante da empresa-vítima e pelos policiais ouvidos em juízo, mostra-se, pois, suficiente à condenação do acusado aos elementos coligidos durante a instrução.

No caso em tela, restou claro que o réu escalou até a parte superior do imóvel com a finalidade de subtrair os fios. No local, logrou êxito em cortar parte da viação, mas foi capturado pelos policiais militares na casa vizinha.

Nesse sentido, apesar do laudo pericial de fls. 98/102 ter concluído apenas que o acesso ao imóvel provavelmente se deu por escalada, a qualificadora da escalada restou devidamente comprovada pela prova oral colhida, já que o próprio réu foi firme em dizer que teria utilizado de uma escada presente na casa vizinha para ter acesso ao andar superior do estabelecimento comercial, onde efetuou a subtração da fiação local, versão que foi corroborada pela oitiva das testemunhas.

Por outro lado, imperioso o reconhecimento da modalidade tentada, uma vez que ficou comprovado que o réu não logrou em consumir a prática delitiva, tendo em vista a chegada da polícia, que o deteve na casa vizinha.

Por fim, no que tange a agravante da calamidade pública, em que pese o entendimento do d. Representante do Ministério Público, entendo que a sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática do delito (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021).

Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva

incidência.

Caracterizada, portanto, a infração penal prevista no 155, §4º, inciso II (escalada) em sua modalidade tentada, passo a dosimetria da pena:

Na primeira fase, verifica-se que o réu era primário a época dos fatos, consoante certidão de fls. 142/144. No entanto, foi condenado definitivamente por delito praticado anteriormente ao crime aqui narrado (autos nº 1511216-44.2021.8.26.0228, da 23ª Vara Criminal de São Paulo), o que embora não configure a agravante da reincidência, caracteriza maus antecedentes a ensejar o acréscimo da pena-base. Este é aliás o entendimento pretoriano que vem sendo adotado, como a seguir se demonstra: "É consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIOSCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). Portanto, desde que transitada em julgado, tal condenação por fato anterior ao apurado é idônea a valorar negativamente os antecedentes do acusado. Acórdão 1310198, 07090202620198070005, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021.

Assim sendo, com fulcro no disposto no art. 59 do Código Penal a pena base deve ser aumentada em 1/6, chegando-se a 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, há que se considerar a confissão do acusado e assim a pena deve ser reduzida e retornar ao patamar mínimo legal estabelecido.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de aumento do repouso noturno com base no recente entendimento do STJ: "A causa de aumento prevista no § 1º do art.155 do Código Penal não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º) STJ. 3ª Seção. REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 25/05/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1087) (Info 738)".

No mais, presente no caso a tentativa, já que o delito de furto não se consumou pois o réu foi surpreendido pelos policiais no momento em que tentava se evadir do local, com os fios sob sua posse. Assim sendo, considerando o iter criminis praticado pelo acusado, que já havia escalado e cortado e guardado os fios para levá-los, a pena deve ser diminuída no mínimo legal de 1/3, e ser fixada em 01 ano e 04 meses de reclusão e 06 dias-multa.

Considerando que não há nos autos provas da condição econômica do acusado, fixa-se o dia multa no mínimo legal estabelecido.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra CLEITON CABRAL para condená-lo à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, por estar incurso no artigo 155, §4º, inciso II c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Inviável é a substituição da pena, de acordo com o art. 44, inciso III, do CP.

Como é sabido, não basta que o acusado satisfaça os requisitos objetivos da lei para ter sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, é necessário, também que os requisitos subjetivos lhe sejam favoráveis, como a seguir se demonstra: "Eventual substituição da pena de privação de liberdade por restritiva de direitos, bem como a estipulação de regime prisional, estão a depender da análise articulada das circunstâncias subjetivas dos pacientes, as quais, in casu, foram inteiramente desfavoráveis".

Veja-se que no caso em tela, além do réu possuir condenação por fato anterior ao crime aqui tratado, tem-se que foi novamente preso pela prática de furto qualificado (autos n. 1526844-73.2021.8.26.0228), após ser concedida liberdade provisória nos presentes autos, o que indica ser insuficiente ao réu a substituição por pena restritiva de direitos.

Sendo também inviável a aplicação do sursis consoante disposto no art. 77, inciso II, do CP.

No entanto, considerando o montante de pena aplicada, a primariedade na data dos fatos do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Tendo permanecido solto, em razão deste processo, poderá apelar desta em liberdade

já que não há elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e oficiem-se IIRGD e TRE.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes. Com a juntada do cálculo aos autos abra-se vista às partes para devida ciência e eventual manifestação.

Comunique-se à vítima, consoante disposição legal.

Condene ainda o réu ao pagamento das custas judiciais, que decorre de expressa previsão legal. Com efeito, o Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Contudo, caso demonstre preencher a hipótese legal, poderá o réu valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, Dje 14/06/2011).

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA